R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile

in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro

all'udienza del **3 ottobre 2023,** all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile iscritta al **n. 6456** del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno **2023** vertente

T R A

Parte_1 **e** *Parte_2* elettivamente domiciliati in Roma, alla via Appia Nuova, n. 103, presso lo studio degli avv.ti Gabriella Arcuri e Marcello Andreozzi, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procure in calce all'atto di citazione

ATTORI

E

Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza del Viminale, n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gallo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: regolarizzazione abusi edilizi

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per gli attori: *"... 1. Preso atto della esistenza di irregolarità urbanistiche relative agli immobili in comunione tra gli eredi* *Parte_1* *e il sig.* *CP_1* *per come emerse dalla CTU relativa al giudizio di divisione ereditaria, valutare la loro sanabilità, nominando all'uopo un perito, al fine in particolare di statuire come risolvere la questione della mancanza di titolo edilizio con riguardo*

all'immobile di Montopoli in Sabina, atteso che in riferimento a questo problema alcuna soluzione è stata prospettata dalla CTU allegata all'atto di citazione; 2. Accertare in carico al sig. *CP_1* *, a sua cura e spese (in considerazione della provenienza degli abusi dall'attività del convenuto),o in alternativa ripartendo le spese secondo le rispettive quote di proprietà, l'obbligo di attivarsi al fine di rimuovere e/o correggere quelle irregolarità che di fatto impediscono allo stato attuale la divisione della comunione ereditaria, o in subordine consentire agli eredi* *Parte_1* *di svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per la rimozione degli abusi stessi".*

Per il convenuto: *"... Rigettare le domande di parte attrice perché inammissibili, nonché infondate in fatto e diritto. Rilevata la palese inammissibilità, si chiede la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc. In via del tutto gradata si chiede che il Giudice sospenda, in attesa della definizione del giudizio pendente avanti la Corte di Appello di Roma RG 8592/2018, il presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c."*.

FATTO E DIRITTO

Parte_1 e *Parte_2* hanno promosso il presente giudizio nel gennaio 2023 al fine di sentir condannare *Controparte_1* alla rimozione o alla sanatoria di irregolarità edilizie relative ad una pluralità di immobili che formano oggetto di una comunione ereditaria tra le parti: irregolarità che sono già state riscontrate da un CTU nel corso di una causa precedentemente instaurata dinanzi a questo stesso Ufficio e che hanno impedito di giungere ad un esito fruttuoso del giudizio divisionale, invero conclusosi con una pronuncia di rigetto. Gli attori hanno in particolare dedotto che quasi tutti gli immobili compresi nella comunione sono stati realizzati in presenza di un regolare titolo edilizio e presentano solo modeste difformità senz'altro sanabili, mentre il solo bene ereditario situato in Montopoli di Sabina è risultato privo di titolo, sebbene costruito in epoca anteriore al 1967 e poi successivamente ampliato.

Controparte_1 , costituitosi in giudizio, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda avversaria.

Così sinteticamente ricostruito l'oggetto di causa, il giudicante rileva che la domanda attorea non è sorretta dal necessario interesse ad agire ed è pertanto inammissibile.

Giova anzitutto evidenziare che la sentenza che ha definito il precedente giudizio di divisione tra le parti (la sentenza n. 10387/2018) è stata resa prima del noto *revirement* compiuto dalla Corte di cassazione in tema di divisione di fabbricati abusivi.

Ed invero, con due recenti arresti resi a Sezioni Unite (n. 8230 e n. 25021 del 2019), la Suprema Corte ha accolto la cd. "teoria formale" in materia di nullità previste dalla disciplina sull'attività edilizia. In particolare, per ciò che qui rileva, è stato chiarito come la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 vada ricondotta nell'ambito del comma terzo dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve quindi qualificarsi come nullità "testuale". Con tale espressione deve intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; titolo che, beninteso, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile. Ne consegue che il negozio che menzioni gli estremi del titolo edilizio, reale e riferibile all'immobile, è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

Occorre inoltre precisare che, con riferimento alle opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 (entrata in vigore della cd. "legge Ponte"), l'art. 40 della l. n. 47 del 1985 consente ai contraenti, in luogo dell'indicazione degli estremi della licenza edilizia, di limitarsi a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'opera risulta iniziata antecedentemente al 1° settembre 1967.

Deve inoltre rilevarsi che soltanto, dapprima, con il d.lgs. n. 301 del 2002 (art. 1, comma 1, lett. s) e, poi, con il d.lgs. n. 222 del 2016 (art. 3, comma 1, lett. u), il legislatore ha esteso la portata della sanzione di nullità prevista all'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 anche ad alcuni interventi edilizi posti in essere successivamente all'attività costruttiva originaria (vd. comma 5-*bis* dell'art. 46 cit.). Di talché, soltanto per gli atti ad effetti reali conclusi dopo l'entrata in vigore del comma 5-*bis* dell'art. 46 cit. e concernenti gli immobili la cui attività costruttiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, possono rilevare, ai fini della sanzione civilistica di nullità, determinati interventi costruttivi successivi all'originaria attività di realizzazione dell'opera.

I principi testé esposti trovano peraltro applicazione non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, non essendovi ragioni per differenziare il regime della divisione a seconda della modalità, contrattuale e giudiziale, con cui essa viene realizzata, e risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative dianzi citate (v. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la regolarità edilizia dell'immobile da dividere costituisce condizione dell'azione *ex* art. 713 c.c. e che nel caso in cui la divisione venga chiesta in via giudiziale, la predetta condizione, che può intervenire in ogni stato e grado del processo, può dirsi sussistente qualora le parti che propongono la domanda producano una dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia ovvero una dichiarazione attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 1° settembre 1967; ciò in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (v. Cass., 29.4.2016, n. 8489; Cass., 22.1.2018, n. 1505).

Venendo al caso che occupa, è assolutamente pacifico tra le parti che alcuni degli immobili in comunione sono stati realizzati sulla base di titoli abilitativi effettivamente esistenti, sebbene presentino alcune difformità

rispetto da essi, mentre l'immobile situato in Montopoli di Sabina è stato costruito, sia pure senza titolo, anteriormente al 1967.

Ne consegue, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che la sussistenza di modificazioni rispetto all'originaria consistenza degli immobili, effettivamente riscontrata dal CTU, pur potendo rilevare sotto altri profili, non comporta la nullità della divisione per violazione della disciplina urbanistica e, pertanto, non osta di per sé all'accoglimento di una domanda giudiziale in tal senso.

Ciò vale anche con riguardo all'immobile costruito senza titolo.

Ed infatti, trattandosi di opera la cui costruzione è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, è sufficiente, al fine di non incorrere nelle nullità previste dalla disciplina urbanistica, che negli atti di causa sia fatta menzione dell'aspetto temporale dell'inizio dell'attività di costruzione e che tale circostanza non risulti falsa, senza che possano a tal fine rilevare eventuali abusi successivamente compiuti.

Questo giudicante non ignora che in giurisprudenza è stato talora attribuito rilievo anche alle trasformazioni realizzate in epoca successiva al 1° settembre 1967 su immobili il cui nucleo originario era stato costruito in data antecedente. Ad esempio, in tal senso si è espressa Cass., Sez. 2, sentenza n. 52 del 07/01/2010 (Rv. 610647 – 01), secondo cui "*A norma dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i beni immobili che abbiano subito, in epoca successiva al 1° settembre 1967, interventi di trasformazione edilizia per i quali sia necessaria la concessione, sono incommerciabili - con conseguente nullità dei relativi atti di trasferimento - ove l'alienante non dia conto degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria o della presentazione della relativa domanda; ad escludere la commerciabilità è sufficiente che l'opera abbia subito modifiche nella sagoma o nel volume rispetto a quelli preesistenti, dovendosi ritenere tale la costruzione di una veranda, locale*

normalmente privo dei connotati di precarietà e destinato a durare nel tempo".

Tuttavia, tale approdo ermeneutico risulta precluso da un compiuto accoglimento della teoria formale e, a ben vedere, rimane predicabile soltanto con riferimento agli immobili la cui costruzione è iniziata successivamente al 17 marzo 1985, in virtù di quanto disposto dal comma 5-*bis* dell'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Ciò non esclude certo il carattere abusivo degli immobili, come rilevato dall'ausiliario del Tribunale nel precedente giudizio. E tuttavia, giova ribadirlo, trattasi di aspetti che, nel caso che occupa, esulano dal tema della "nullità urbanistica", la cui verifica si arresta al profilo formale dell'accertamento della menzione negli atti dei titoli urbanistici reali e riferibili agli immobili, ovvero della dichiarazione di inizio dell'attività costruttiva in data antecedente al 1° settembre 1967.

Dal momento che l'interesse che muove gli attori a chiedere nella presente sede la regolarizzazione degli abusi è dichiaratamente solo quello di poter procedere alla divisione, e considerato quanto già esposto circa l'ininfluenza di tali abusi ai fini del valido compimento delle operazioni divisionali alla luce del sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

Deve poi respingersi la domanda diretta alla condanna degli attori al risarcimento dei danni *ex* art. 96 c.p.c. giacché di tali danni – a prescindere da ogni altra considerazione sulla sussistenza degli altri presupposti legali della responsabilità aggravata – non vi è prova di sorta.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. - rigetta la domanda proposta da *Parte_1* e *[...]* *Parte_2* ;

2. - condanna *Parte_1* e *Parte_2* al pagamento, in favore di *Controparte_1*, delle spese del giudizio che liquida in complessivi €2.800,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.

Roma, 3 ottobre 2023

Il Giudice

Luigi D'Alessandro